

N. R.G. 2251/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Prima civile

composta dai Signori

Massimo Meroni

- Presidente

Serena Baccolini

- Consigliere

Silvia Giani

-Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG. N. 2251/2020 promossa in grado di appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio
dell'avv. MARCINKIEWICZ ANDREA e dell'avv. FRANZINI MARCO
(*C.F._2*) VIA CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO,
elettivamente domiciliato in Via CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO
presso il difensore avv. MARCINKIEWICZ ANDREA

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 *P.IVA_1*) in persona del legale
rappresentante, e per essa *Controparte_2* e per
essa *Controparte_3* rappresentata e difesa con il

patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv. CONCIO FRANCESCO
elettivamente domiciliato in Milano, via Vittoria Colonna n. 2

APPELLATA

Oggetto: *fideiussione. Nullità clausole ABI per violazione antitrust*

Per parte appellante *Parte_1* .:

in via preliminare di rito:

Accertarsi e dichiararsi la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata del Tribunale Ordinario di Sondrio, con ogni conseguente opportuna statuizione.

Nel merito:

in parziale riforma della sentenza appellata n. 199/2020, emessa dal Tribunale Ordinario di Sondrio in data 22 luglio 2020, ex art. 281-sexies c.p.c., accogliersi l'eccezione di nullità della fidejussione proposta da *Pt_1*

[...] e, per l'effetto, respingersi tutte le domande svolte dall'attrice appellata *Controparte_1* (e per essa da *Controparte_2*

[...] e per essa da *Controparte_3* , in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarandosi che *Parte_1* nulla deve all'appellata. Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, da gravarsi di oneri fiscali”.

*

per parte appellata *Controparte_1*

Tutto ciò premesso *Controparte_1* e per esso la *[...]*

Controparte_2 , e per essa *Controparte_3*

[...] , come sopra rappresentata e difesa, nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito accolga le seguenti

Conclusioni

in via preliminare:

rigettare l'istanza di sospensione della sentenza ex art. 283 c.p.c.

In via principale

rigettare tutte le domande avanzate dal sig. Pt_1, e confermare interamente la sentenza n. 199/2020 del 22/07/2020;

in via istruttoria:

previo rigetto di ogni avversaria richiesta, e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini processuali che verranno assegnati;

in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

MOTIVAZIONE

1. Il giudizio di primo grado.

Con sentenza n. 199/2020 il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro Controparte_1 ha così deciso:

P.Q.M.

- *accoglie in parte l'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 e per essa Controparte_2 e per essa Controparte_3 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 333/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio;*

- *condanna Parte_1 a pagare nei confronti di Controparte_1 e per essa Controparte_2 e per essa [...] Controparte_3 la somma di € 511.955,3, oltre interessi come per legge;*

- condanna *Parte_1* a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 18.452,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.

2. *Parte_1* citava in giudizio *Controparte_1* proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2019, con cui il Tribunale di Sondrio ingiungeva all'attrice di pagare la somma di euro 541.164,71 oltre interessi e spese del procedimento, in forza della fideiussione *omnibus* del 24 febbraio 2010, sottoscritta nell'interesse di *Controparte_4* per i debiti da quest'ultima contratti nei confronti di *Organizzazione_1* derivanti da mutuo fondiario stipulato da *Organizzazione_1* e *CP_4* il 21 febbraio 2020 e finanziamento chirografario concesso da *Organizzazione_1* a *CP_4* il 18 aprile 2013.

La parte opponente eccepiva che:

- la fideiussione era nulla in quanto “contratto a valle” di un'intesa vietata ex art. 2, comma 2, della legge 10/10/1990 n. 287;

- il concordato preventivo della debitrice principale *CP_4* omologato il 11/10/2017 dal Tribunale di Como, a seguito del riparto dell'attivo avvenuto in data 10/6/2019, aveva pagato ad *CP_1* la somma di € 29.209,41 e che altri pagamenti stavano per essere ulteriormente corrisposti.

3. Si costituiva la parte opposta *Controparte_1*, domandando il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

4. *L'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado può essere così sintetizzato.*

Il giudice di prime cure riteneva non ammissibile il rimedio giudiziale della nullità derivata, affermando che l'unica tutela concessa al soggetto estraneo all'intesa anticoncorrenziale fosse quella risarcitoria, sul presupposto che il divieto di intese concorrenziali di cui all'art. 2 L 287/1990 non incidesse direttamente sul contenuto degli atti negoziali, ma sui soli comportamenti (Cass. 13846/2019).

Accertava l'avvenuto parziale adempimento da parte della debitrice principale, successivo alla notifica del decreto ingiuntivo, nella misura di € 29.209,41, a seguito di riparto dell'attivo concordatario della debitrice principale (cfr. doc. 7 opponente), ritenendo che fossero irrilevanti le ulteriori somme che non risultavano ancora essere state effettivamente corrisposte.

Il giudizio di appello

5. La sentenza del Tribunale di Sondrio è stata impugnata da Pt_1 [...], che ne ha chiesto la riforma sulla base dell'unico motivo relativo all'erronea statuizione in merito all'eccezione di nullità della fidejussione per violazione della normativa antitrust.

6 Controparte_1 si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

7. Alla prima udienza del 24 marzo 2021, dopo che le parti, su invito della Corte, hanno precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Preliminarmente si osserva che la decisione sull'eccezione di parziale pagamento per l'importo di euro 29.209,41 non è stata impugnata e pertanto è coperta da giudicato interno.

9. *La nullità delle clausole ABI.* Con l'unico motivo di appello, il sig. Pt_1 [...] ha censurato la sentenza di prime cure per non avere dichiarato la nullità assoluta della fideiussione *omnibus* sottoscritta secondo lo schema

diffuso dall'ABI contenente le clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. In subordine, si è doluto che non fosse stata accertata la nullità parziale del negozio fideiussorio ai sensi dell'art. 1419 comma 2 c.c. e, nell'ipotesi di sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma di cui all'art. 1957 c.c., che non fosse dichiarato il decorso del termine previsto per la proposizione a carico del creditore dell'istanza di pagamento contro il debitore, in quanto:

il contratto di finanziamento, sottoscritto il 18 aprile 2013 (doc. 6 fascicolo monitorio), prevedeva che l'obbligazione principale scadesse il 30 giugno 2016, data corrispondente con la scadenza della prima rata; la raccomandata, con cui era stato risolto il contratto di mutuo era stata inviata da CP_5 al debitore principale, CP_4 e ad Parte_1 il 23 febbraio 2017. L'appellante affermava quindi che, poiché l'atto stragiudiziale non era sufficiente agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c. (Cass. 7502/2004), anche ravvisando una nullità parziale del negozio fideiussorio, l'azione del creditore fosse infondata, per decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. Chiedeva, pertanto, che, in accoglimento dell'appello, le domande proposte da CP_1 fossero rigettate.

10. L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza, ritenendo che la nullità delle intese anticoncorrenziali fra imprese a monte non comporti, di per sé, la nullità dei contratti conclusi a valle fra la banca e i terzi.

Con specifico riguardo alla decadenza ex art. 1957 c.c., ne ha argomentato l'infondatezza, essendo documentato l'invio alla debitrice principale e al garante della comunicazione datata 23/2/2017, con cui il creditore aveva intimato il pagamento delle somme dovute in forza dei rapporti contrattuali. Poiché la fideiussione *omnibus* era a prima richiesta, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità – espresso da Cass.

22346/2017, Cass. 13078/2008, 16836/2015- tale pattuizione determinava una deroga pattizia alla forma con cui dovesse essere avanzata dal creditore l'istanza ex art. 1957 c.c., essendo sufficiente per le fideiussioni a prima richiesta la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento.

11. Valutazione della Corte

L'appello non è fondato e la sentenza impugnata va confermata.

11.1. Quale unico motivo di appello, la garante ha eccepito la nullità della fideiussione prestata, in quanto conforme allo schema negoziale predisposto dall'associazione bancaria italiana ^{Organi} che è stato dichiarato nullo per contrarietà con l'art. 2 L. 287/90 in materia di divieto di intese restrittive della concorrenza ed in seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di ^{Org_3}.

Come noto, la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla ^{Org_3} in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all' ^{Org_4}, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni *omnibus* predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 ("Legge Antitrust"), in virtù della quale "1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili; 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...); 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."

La banca d'Italia, soggetto responsabile pro tempore dell'*enforcement* antitrust ha quindi ritenuto che le clausole 2, 6 e 8 del detto schema contrattuale fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett a) L 287/90 nella misura in cui fossero applicate in modo uniforme.

11.2. Ciò premesso, è ben noto a questa Corte l'ampio dibattito in dottrina sui rimedi ammissibili nel caso di accordo esecutivo (o semplicemente "consecutivo") di un'intesa vietata perché in violazione della normativa antitrust. Poiché l'art. 2 L. n. 287/1990 (così come il corrispondente art. 101 TFEU) prevede espressamente la nullità delle sole "intese", è controverso quali siano i rimedi esperibili per gli accordi conclusi a valle, dovendosi anzitutto verificare se essi siano attuativi dell'intesa vietata o meno (cfr., in giurisprudenza, T. Roma 7548/2021).

Nel caso di specie, tuttavia, la questione non è decisiva.

Anche non aderendo all'orientamento manifestato dal giudice *a quo* - dell'inammissibilità del rimedio della nullità dell'accordo a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza- tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, condivisa anche da questa Corte, la nullità delle singole clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. non incide sulla validità dell'intero contratto giacché i contraenti lo avrebbero ugualmente concluso senza la clausola colpita da nullità (art. 1419 secondo comma c.c.). Infatti, le clausole in questione sono funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (Cass. 24044/19).

Di conseguenza, come argomentato anche dall'appellante, la clausola pattizia in deroga all'art. 1957 c.c. è espunta dalla fideiussione e sostituita dall'art. 1957 c.c.

11.3. La questione decisiva nel presente processo, allora, è quale sia la forma dell'istanza di pagamento prevista dall'art. 1957 c.c., onde non incorrere nella decadenza prevista da tale norma. In altre parole, se sia necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale o sia sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento.

11.3.1. La Suprema Corte, con la pronuncia n. 22346/2017, ha statuito che, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. sia soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, affermando che "in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (nello stesso senso, anche, Cass. 13078/2008, Cass. 7345/95). La Suprema Corte ha invero argomentato che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che la volontà contrattuale d'imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso

che tale richiesta si debba manifestare con l'azione giudiziaria (Cass. 13078/2008 cit.).

11.3.2. Nel caso di specie, la fideiussione *omnibus* è del tipo a prima richiesta, atteso che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta e senza eccezioni.

La clausola che consente al creditore di chiedere al fideiussore il pagamento a semplice richiesta scritta, rimossa ogni eccezione, produce l'effetto di rendere l' obbligazione fideiussoria autonoma rispetto all' obbligazione principale. In considerazione di tale autonomia, quand' anche l'articolo 1957 c.c. fosse applicabile, per effetto di nullità (parziale) della clausola di esonero, il disposto di tale norma dovrebbe essere interpretato in modo compatibile con la natura autonoma della garanzia fideiussoria, che abilita il creditore a rivolgersi al garante a prima richiesta scritta e senza che questo possa opporre eccezioni all' obbligazione principale.

Deriva da ciò e da tale autonomia che l' escussione della garanzia non possa essere subordinata al previo esperimento di azioni giudiziarie per fare valere l' obbligazione principale, pena la perdita della natura autonoma della garanzia fideiussoria.

Deve pertanto ritenersi che nella garanzia autonoma a prima richiesta l' onere di fare valere l'istanza contro il debitore principale risulti soddisfatto con l'invio a quest'ultimo della richiesta di pagamento di tale obbligazione.

Nel caso in esame risulta che la banca, con lettera 23 febbraio 2017, inviata al debitore principale (e altresì al garante), ha risolto il rapporto di mutuo e ha chiesto il pagamento e tanto basta a soddisfare l' onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta.

12. La sentenza del Tribunale di Sondrio deve essere pertanto confermata.

13. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dell'assenza della fase istruttoria e della presenza di una sola udienza, seguono la soccombenza, che è in capo all'appellante.

14. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 per la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da *Parte_1* nei confronti di [...]

CP_1, così dispone:

I. rigetta l'appello e conferma la sentenza n.199/2020 del Tribunale di Sondrio;

II. Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *Controparte_1*, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;

III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 17 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Dott. Silvia Giani

Il Presidente

dott. Massimo Meroni